

1500579-44.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de estabilidade e permanência de grupo criminoso voltado para o tráfico, com elementos que sinalizem reiteração de conduta e organização das ações, com divisão ordenada e hierarquizada, fato não demonstrado nos presentes autos.

Neste sentido presente julgado: "AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500579-44.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500579-44.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO SOARES e outro

Autos nº 151/2021 (1500579-44.2021.8.26.0548)

Vistos etc.,

I - Paulo Henrique Fernandes Rodrigues, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA e MÁRCIO SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, em data anterior ao dia 17 de fevereiro de 2021, nesta cidade e comarca de Campinas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Ainda, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Dracena, em frente ao número 87, Jardim Itatinga, nesta comarca e cidade de Campinas, Paulo, devidamente associado com GABRIEL e MÁRCIO, trazia consigo, para consumo de terceiros, 06 (seis) porções de cocaína, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No mais, na mesma ocasião, no interior de um quarto, na casa noturna situada na Rua Dracena, nº 87, Jardim Itatinga, também nesta cidade e comarca de Campinas, Paulo, devidamente associado com GABRIEL e MÁRCIO, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 47 (quarenta e sete) porções de cocaína e 10 (dez) frascos de lança-perfume, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Ademais, no mesmo dia, no interior de um quarto do bar situado na Rua Guaíçara, nº 98871, Jardim Itatinga, nesta cidade e comarca de Campinas, GABRIEL, devidamente associado com Paulo e MÁRCIO, trazia consigo, para consumo de terceiros, 10 (dez) tablets e 11 (onze) porções de maconha e 10 (dez) porções de cocaína, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, no mesmo dia, no interior da residência situada na Rua Maximiliano Weinlinch, nº 130, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade e comarca de Campinas, MÁRCIO, devidamente associado com Paulo e GABRIEL, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de maconha, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificados (fls. 218 e 219), os réus Gabriel e Márcio apresentaram defesa prévia (fls. 272/277 e 300/323).

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 12 de abril de 2021 somente em relação ao réus Gabriel e Márcio, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 335/336).

O acusado Paulo Henrique não foi localizado pessoalmente para notificação (fls. 628), tendo sido apresentada defesa prévia por intermédio da Defensora Pública nomeada (fls. 638/639) e recebida a denúncia em relação a ele na data de 14 de junho de 2021 (fls. 644).

Ainda, o réu Paulo Henrique foi citado por edital (fls. 670/671) e houve a determinação da suspensão do prazo e do curso da prescrição nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal somente em relação a ele (fls. 702).

Então, os acusados Gabriel e Márcio foram citados pessoalmente (fls. 791 e 792).

O réu Paulo também foi citado pessoalmente (fls. 874).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 27/09/2021, foi ouvida uma testemunha de acusação e, em 01/02/2022, uma outra testemunha de acusação, uma testemunha de defesa e os acusados interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 854 e 1038).

Os autos foram desmembrados em relação aos réu Paulo (fls. 877/881).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, bem como o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 1043/1051). A Defesa de Gabriel, pugnou pela absolvição do acusado (fls. 1055/1065). A Defesa de Márcio, pleiteou a absolvição e, em caso de condenação: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; c) a isenção do pagamento da pena de multa; d) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; e) o direito de recorrer em liberdade; f) o reconhecimento da justiça gratuita (fls. 1066/1086).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), Guias de Depósitos Judiciais (fls. 149 e 150), Laudo Químico-Toxicológico (fls. 151/155), Áudio (fls. 382), BOPM (fls. 385/399) e Laudo Químico-Toxicológico Complementar (798/802).

Quanto à autoria, o réu Gabriel disse que estava na pensão em que residia sozinho em um quarto, momento em que os policiais ordenaram que abrisse a porta. Afirmou ter sido questionado acerca de Paulo, tendo negado conhecê-lo. Ainda, esclareceu que os policiais determinaram que desbloqueasse o seu celular e passaram a mexer no aparelho, momento em que eles viram uma mensagem enviada por Márcio acerca de um dinheiro. Acrescentou que o corréu lhe adiantou uma certa quantia referente a um trabalho de jardinagem que prestaram juntos. Disse que os policiais passaram a conversar com Márcio, tendo se passado pelo interrogando. Ainda afirmou que possuía uma mochila de cor rosa e negou a posse de drogas, tendo apenas admitido a posse da quantia de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Posteriormente, disse que, ao sair da cadeia, Márcio lhe emprestou a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo cobrado este valor na mensagem enviada quando os policiais estavam na posse de seu celular. No mais, negou ter fornecido o endereço de Márcio aos

policiais, tendo sido o próprio corréu quem enviou o endereço ao pensar que falava com o interrogando. Por fim, afirmou que o indivíduo conhecido como "Tio Zu" os acompanhou até a residência de Márcio.

O acusado Márcio disse ter sido abordado enquanto brincava no portão de sua casa com o seu cachorro. Esclareceu já ter sido abordado pelo policial militar Bruno em data anterior à ocorrência, ocasião em que os agentes anotaram o seu endereço. Esclareceu que os policiais entraram sem autorização em sua casa, tendo mexido no seu celular e no celular de sua esposa e encontrado a quantia de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Negou a apreensão de entorpecentes no local. Afirmou ter enviado mensagem para Gabriel, momento em que cobrou que ele pagasse o que lhe era devido, tendo ele pedido o seu endereço. Por fim, esclareceu que residia há quatro meses naquele local.

No entanto, o policial militar Bruno relatou que realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Itatinga, momento em que avistou o acusado Paulo que saía de uma casa. Esclareceu que o réu, ao perceber a presença policial, mudou o trajeto que percorria, tendo sido abordado. Em revista pessoal, apreendeu aproximadamente R\$ 86,00 (oitenta e seis reais) em dinheiro e seis porções de cocaína, momento que ele confessou o tráfico no local. Ainda, localizou, no interior de um quarto da casa, outras porções de cocaína e frascos de lança-perfume. Esclareceu que Paulo não estava na posse dos documentos pessoais, tendo sido conduzido até o quarto em que residia, em um bar nas proximidades, para buscá-los. Disse que nos fundos deste local havia uma estrutura de alvenaria que funcionava como uma pensão, tendo aí avistado Gabriel que tentou retornar ao seu quarto ao perceber a presença policial. Acrescentou que Gabriel foi abordado e, em sua mochila, apreendeu porções de maconha e cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais), tendo ele indicado Márcio como o responsável pelo fornecimento de drogas para venda na região. Por fim, Gabriel indicou o endereço de Márcio, local em que houve a apreensão de cerca de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro e um tijolo de maconha em uma embalagem de cor verde, não tendo se recordado se estava acondicionada em uma sacola de cor preta ou mochila. Ainda, disse que possivelmente o acusado Gabriel os acompanhou na viatura, tendo informado o endereço e indicado o trajeto até a residência de Márcio. Ademais, afirmou que a abordagem se deu no final da tarde; no entanto, não soube informar o horário exato. No mais, não se recordou de ter manipulado os celulares dos acusados e negou tê-los abordado anteriormente. Ainda, não soube informar se o RG de Paulo foi localizado em seu quarto. Por fim, os reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Ulisses que acrescentou que no momento em que avistou Gabriel ele havia saído de seu quarto e, ao perceber a presença policial, tentou adentrar em um quarto diferente do seu. Ainda, em sua mochila, de cor preta, foi apreendido um celular, além de dinheiro e porções de maconha e cocaína, tendo ele confessado que traficava no local e indicado Márcio como o responsável pelo fornecimento de drogas. Ainda, negou ter tido acesso aos dados do celular de Gabriel, tendo ele indicado o endereço de Márcio. Em diligências ao local indicado, avistou Márcio ao telefone em frente à sua residência, não tendo apreendido nada de ilícito em revista pessoal. No mais, questionado e informado acerca da confissão de Gabriel, Márcio admitiu que fornecia drogas para tráfico no bairro Jardim Itatinga, tendo franqueado a entrada em sua casa, local em que foi apreendido um tijolo de maconha acondicionado em uma sacola de cor branca de supermercado em cima do armário da cozinha, bem como dinheiro e dois celulares. Ademais, disse que a esposa de Márcio estava na residência, ocasião em que presenciou a localização da droga, tendo negado ter manipulado o seu celular. No mais, acrescentou que a abordagem de Gabriel foi casual e aparentemente não teve relação com a de Paulo. Ainda, não soube informar em que momento foi realizada a consulta aos antecedentes dos acusados via COPOM, tendo esclarecido que ela pode ocorrer de imediato ou no curso da diligência. Por fim, os reconheceu em audiência.

A testemunha de defesa Fabíola, esposa do acusado Márcio, disse que o seu marido saiu para passear com o cachorro enquanto permaneceu no quarto, momento em que avistou os policiais adentrarem a residência com uma arma apontada para Márcio.

Ainda, mexeram em seu celular e a questionaram acerca da presença de armas e drogas no local. Disse que somente foi apreendida a quantia de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) que seria utilizada para o pagamento do aluguel. No mais, Márcio havia comentado acerca da sua abordagem pelo policial Bruno em data anterior. Por fim, confirmou que os policiais manipularam o celular de seu marido e fizeram ligações, tendo exigido armas e dinheiro.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação dos réus com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares que foram uníssonos e coerentes no sentido de que, após a abordagem de Paulo, avistaram o acusado Gabriel em atitude suspeita, tendo apreendido em sua posse porções de maconha, cocaína e dinheiro. Ainda, Gabriel indicou Márcio como o responsável pelo fornecimento de drogas na região, tendo fornecido o seu endereço. Por fim, no local indicado por Gabriel, no interior da residência de Márcio, foram apreendidos um tijolo de maconha e dinheiro. Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos policiais, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente os réus.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (STJ - Habeas Corpus 115516/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009)

E ainda: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ainda, muito embora o acusado Márcio tenha afirmado ter sido abordado pelo policial Bruno em data anterior, o agente negou conhecer os réus ou tê-los abordado anteriormente.

Ademais, no áudio juntado a fls. 382, é possível notar que os policiais efetuaram uma pesquisa de antecedentes criminais dos acusados junto ao COPOM e o fato de ter sido mencionada a Rua Dracena como local da abordagem não tem o alcance pretendido pela Defesa.

Nota-se que neste endereço foi realizada a primeira abordagem, de Paulo, e é o que consta como principal inclusive no BOPM juntado a fls. 385; no entanto, é possível notar que neste próprio documento foram posteriormente mencionados os outros endereços.

Ainda, conforme esclarecido pelo policial Ulisses em juízo, esta consulta ao COPOM pode ser realizada de imediato ou durante toda a abordagem; portanto, o fato dos policiais terem mencionado a Rua Dracena não significa que todo o ocorrido se deu naquele local.

No mais, não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade as prisões, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade quando da sua análise (fls. 115/117).

Quanto à abordagem de Gabriel, foi respeitada a inviolabilidade do domicílio como previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal já que se tratava de habitação coletiva e o acusado foi abordado quando já estava fora de seu quarto, no corredor do imóvel.

No mais, não há que se falar em depoimentos duvidosos dos policiais que narraram de forma harmônica que o réu Paulo não portava os documentos pessoais, tendo se dirigido ao local de abordagem de Gabriel para buscá-los.

E ainda que os policiais não tenham confirmado a apreensão dos documentos de Paulo, isto não invalida os depoimentos prestados.

Neste mesmo sentido, o fato do policial Bruno não se recordar se Paulo o acompanhou na diligência ao local de abordagem de Gabriel não tem o alcance pretendido pela Defesa; tais dissensões não tem o condão de fragilizar a segura prova acusatória no que tange à apreensão do entorpecente e das atividades indicativas do tráfico.

Os policiais militares, como se sabe, fazem diversos patrulhamentos e diversas prisões e somente um fato concreto poderia impugnar o teor de seus depoimentos. É

plenamente justificável o esquecimento de detalhes das ocorrências com as quais têm contato; assim, basta que seus depoimentos sejam coesos e harmônicos no que se refere à essência do fato delituoso. O fato é que os réus foram abordados na posse das drogas.

Nesse sentido: "Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Flagrante forjado. Inocorrência. Invalidade dos depoimentos das testemunhas policiais Declarações coesas nos pontos fulcrais, que são corroboradas pelas demais provas dos autos. Eventuais divergências sobre questões secundárias não possuem o condão de desacreditar as falas. Validade. Precedentes. Condenação mantida." (TJ/SP - Apelação nº 0013590- 31.2009.8.26.0066, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 14 de junho de 2012, relator Des. Silmar Fernandes).

Desta mesma forma, não tem relevância o fato dos policiais não terem esclarecido por qual motivo a mochila de Gabriel não consta do Auto de Exibição e Apreensão; o policial Bruno disse que geralmente os objetos utilizados para acondicionar a droga são descartados e somente o entorpecente colocado em uma embalagem com lacre; enquanto o policial Ulisses confirmou que a mochila foi apresentada na delegacia. Acerca da abordagem do acusado Márcio, como se sabe, o delito de tráfico de drogas na modalidade "guardar" e "ter em depósito" se trata de crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio desde que presentes fundadas razões quanto à ocorrência de flagrante delito em seu interior.

Neste sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso, conforme se infere dos autos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o agravante estaria armazenando drogas no Bairro Monte Castelo. Diante disso, os militares deslocaram-se até a residência do réu, que autorizou o ingresso dos policiais para averiguação. A ação policial logrou êxito na apreensão de 11kg de maconha. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 6. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 11kg de maconha, ele "é reincidente, tendo sido condenado recentemente, pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Criciúma, à pena de 3 anos de reclusão, por infração ao delito de porte de arma de fogo." 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 598.642/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

No caso em tela, o próprio corréu Gabriel indicou Márcio como o responsável pelo fornecimento de drogas para tráfico na região do bairro Jardim Itatinga, tendo apontado o seu endereço.

Aliás, não houve divergências entre os relatos dos policiais quanto ao fato de Gabriel ter indicado o endereço e, após, ter guiado a equipe até o local.

E, ainda, o próprio Márcio franqueou a entrada em sua casa, conforme depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem.

Quanto ao local exato da cozinha em que foi apreendido o entorpecente na residência de Márcio, o policial Bruno esclareceu não saber ao certo já que a revista foi

realizada por outro agente.

Também não tem qualquer relevância a divergência entre os depoimentos dos policiais acerca da cor da sacola em que estava acondicionada a droga localizada na residência de Márcio.

No mais, a versão apresentada pelos réus no sentido de que não estavam na posse de qualquer entorpecente restou completamente isolada nos autos.

Neste ponto, importante destacar que os acusados Gabriel e Márcio, quando interrogados na fase policial, negaram se conhecer anteriormente (fls. 16 e 17), tendo alterado esta versão em juízo, momento em que Gabriel afirmou que Márcio havia lhe encontrado um emprego e emprestado dinheiro e Márcio alegou que Gabriel lhe devia certa quantia em dinheiro.

Também Gabriel, em juízo, entrou em contradição ao esclarecer a origem do dinheiro que supostamente devia a Márcio e ele estaria lhe cobrando através das mensagens de celular. Inicialmente disse que ele e Márcio prestaram juntos um serviço de jardinagem e Márcio havia lhe adiantado a quantia de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); no entanto, após, alterou a versão apresentada e afirmou que, ao sair da cadeia, Márcio teria lhe emprestado a quantia de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ainda, Gabriel afirmou que já havia sido abordado anteriormente pelos mesmos policiais, momento em que anotaram o seu endereço; desta forma, a alegação da Defesa no sentido de que os policiais se fizeram passar por Gabriel para obter a localização de Márcio não tem qualquer fundamento já que, pela versão apresentada pelo próprio réu, o policial Bruno já tinha conhecimento acerca de seu endereço. No mais, o próprio acusado Márcio afirmou em juízo ter fornecido o seu endereço ao corréu Gabriel, pois ele lhe devia dinheiro.

Ainda, como bem colocado pelo Ministério Público, a análise de eventuais mensagens trocadas pelos acusados após as 17 horas não tem o alcance pretendido pela Defesa. Primeiramente insta consignar que, ainda que no Boletim de Ocorrência juntado a fls. 21/24 conste que a ocorrência se deu às 17 horas, ressalto que no BOPM juntado consta como hora do fato 19h47min (fls. 385).

Acerca da abordagem, o policial Bruno não se recordou do horário exato, tendo dito que ocorreu do meio ao final da tarde; enquanto o policial Ulisses disse não se recordar do horário exato da abordagem já que foram três acusados em três locais diferentes.

Portanto, importante ressaltar que a abordagem dos três acusados se deu em locais diversos, o que torna impreciso o horário constante do boletim de ocorrência.

No mais, ainda que conste a troca de mensagens entre os acusados Gabriel e Márcio por intermédio do aplicativo whatsapp em horário próximo ao da abordagem, este fato é insuficiente para comprovar a versão oferecida pelos acusados no sentido de que os seus celulares foram utilizados de forma indevida pelos policiais.

Neste mesmo sentido o depoimento de Fabíola deve ser analisado com cautela já que é esposa de Márcio.

Ainda, como bem colocado pelo Ministério Público, como Gabriel disse quando da abordagem que vendia a droga fornecida por Márcio, seria comum a troca de mensagens pelo celular e que Márcio lhe cobrasse o dinheiro devido.

Desta forma, não há que se falar em “fruto da árvore envenenada”, violação de sigilo ou nulidade das provas obtidas em razão de alegado uso indevido dos celulares como pretendido pela Defesa.

Cumprе ressaltar que o policial Ulisses negou ter violado o sigilo dos celulares apreendidos; por outro lado, o policial Bruno esclareceu não se recordar se o próprio réu Márcio mostrou o conteúdo do celular em uma tentativa de confirmar a propriedade do aparelho.

No mais, destaco a grande quantidade de droga apreendida (236,19g de maconha e 5,21g de cocaína na posse de Gabriel e 369,6g de maconha na residência de Márcio) e a forma como estava acondicionada (tanto em porções individuais quanto na forma de tijolo), o que reforça a sua destinação para o tráfico.

Ainda, importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz

com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelos agentes foi a de "trazer consigo" (Gabriel) e "guardar" e "ter em depósito" (Márcio).

No entanto, não há que se falar em condenação dos acusados no que concerne ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, por absoluta falta dos requisitos legais.

Ainda que no presente caso tenha ocorrido uma associação eventual, o delito em questão resta configurado mediante prova de estabilidade e permanência de grupo criminoso voltado para o tráfico, com elementos que sinalizem reiteração de conduta e organização das ações, com divisão ordenada e hierarquizada, fato não demonstrado nos presentes autos.

Neste sentido presente julgado: "AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa e a quantidade de drogas denotem envolvimento com atividades criminosas, não há na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar, de forma efetiva, o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, imperiosa é a absolvição. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no HC 471.155/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)

Por fim, equivocou-se a Defesa acerca da falta de intimação da decisão de fls. 614, tendo sido intimada a fls. 688.

Desse modo, feita essa consideração final, a condenação dos réus, pela prática apenas do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, é de rigor. Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 33, "CAPUT", LEI Nº 11.343/06 - RÉU GABRIEL - Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a quantidade de entorpecente apreendido (236,19g de maconha e 5,21g de cocaína), fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou jardineiro (fls. 42). Por fim, tendo em vista a reincidência do acusado (autos nº 0000150-59.2018.8.26.0548 da 3ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 88/89), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Ainda, não há que se falar que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei

n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017)

PENA - ARTIGO 33, "CAPUT", LEI Nº 11.343/06 - RÉU MÁRCIO - Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a quantidade de entorpecente apreendido (369,6g de maconha), fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou pintor (fls. 43). Por fim, tendo em vista a reincidência do acusado (autos nº 0011080-90.2012.8.26.0114 desta 1ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 92/93), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Ainda, não há que se falar que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes."

(STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017)

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado GABRIEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos (RG nº 38.337.210 - I.I.R.G.D. - fls. 285), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda, verifico que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado levando em conta também a grande quantidade de droga (236,19g de maconha e 5,21g de cocaína), o que indica a prática do delito de tráfico em maior escala (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a modificação dada pela Lei nº 11.464/07). Deve-se observar, contudo, que cabe ao juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu Gabriel na prisão em que se encontra.

A.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o acusado MÁRCIO SOARES, qualificado nos autos (RG nº 27.133.081 - I.I.R.G.D. - fls. 289), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no



artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda, verifico que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado levando em conta também a grande quantidade de droga (369,6g de maconha), o que indica a prática do delito de tráfico em maior escala (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a modificação dada pela Lei nº 11.464/07).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu Márcio na prisão em que se encontra.

B.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro "Rol dos Culpados".

Por fim, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 1.487,00 e R\$ 1.045,00 - Guias de Depósitos Judiciais de fls. 149 e 150), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Ademais, pontuo que não cumpre o afastamento de pena de multa, conforme requerido pela Defesa do réu Adilson. A pena de multa é condenação cumulativa à pena privativa de liberdade, conforme previsão do preceito secundário da norma penal, de modo que não cumpre a esta Magistrada a sua consideração parcial.

Nesse sentido: "O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. (...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo." (STJ - AgRg no AREsp 1335772 / PE - Rel. Min.

LAURITA VAZ - Sexta Turma - j. 04/02/2020)

Custas pelos acusados (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressaltado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Por fim, não há que se discutir neste juízo acerca da concessão do benefício da justiça gratuita. Neste sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

P. R. I. C.

Campinas, 24 de fevereiro de 2022.

Patrícia Suárez Pae Kim

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA